



论企业数据出境之合规困境 与优化路径

黄 清 新 *

内容摘要：在跨境数字贸易中，我国企业数据出境合规治理面临国内法规定尚不完善、国外政策环境日益复杂的风险。合理之纾困路径在于，构建独立于个人数据的企业数据出境合规规则，并强化国际合作。企业数据出境合规规制的总体思路为，在规制理念层面，坚持企业数据出境安全流动前提下的自由流动；在规制逻辑层面，技术上应将企业数据与个人数据、公共数据进行剥离，法律上对企业数据进行合理确权及分类分级治理。依循该思路，应将企业数据类型化为可剥离的企业数据与不可剥离企业数据的数据集合，并根据数据级别进行区分规制。与此同时，应积极推动制定并签署WTO企业数据出境合规国际条约，并依托“一带一路”的政策优势，与沿线国家缔结企业数据跨境流动合规的双边投资协定，从而为企业数据出境合规提供国际保障。

关键词：企业数据出境 合规治理 数据分类分级 国际合作

在数字贸易中，数据跨境流动的现象日益频繁。^{〔1〕}数据跨境流动，系国家间数据的电子化移动，^{〔2〕}其包括数据跨越国界的传输与处理、第三国主体能够获得与访问国内数据两种形式。^{〔3〕}毋庸置疑，数据跨境流动已逐渐成为数字贸易的重要形式。^{〔4〕}尽管数据跨境流动包括数据出境与数据入境，但本国数据传输至国外（数据出境）对本国经济社会安全的潜在影响，方为立法关注之重点。在立法层面，2021年《中华人民共和国个人信息保护法》（以下称《个保法》）第38条规定了安全评估、保护认证、标准合同三种数据跨境传输合规方式。此后，《数据出境安全评估办法（2022）》（以下称《安全评估办法》）、《个人信息保护认证实施规则（2022）》（以下称《认证实施规则》）、《个

* 中南财经政法大学法学院博士研究生。

本文系中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项项目“违约获益剥夺之体系反思与教义重构”（202410615）的阶段性成果。

〔1〕 Paul Lambert, *Data Protection and Data Transfers Law* 3 (Bloomsbury Publishing 2023).

〔2〕 Dorine R. Seidman, *Transborder Data Flow: Regulation of International Information Flow and the Brazilian Example*, 1 *Journal of Law and Technology* 31 (1986).

〔3〕 石月：《数字经济环境下的跨境数据流动管理》，《信息安全与通信保密》2015年第10期，第101页；王融：《大数据时代数据保护与流动规则》，人民邮电出版社2017年版，第246页。

〔4〕 W. Gregory Voss, *Cross-Border Data Flows, the GDPR, and Data Governance*, 29 *Washington International Law Journal* 485 (2020).

人信息出境标准合同办法(2023)》(以下称《标准合同办法》)陆续出台,对《个保法》的数据出境合规规定进行了细化。此外,2024年3月开始施行的《促进和规范数据跨境流动规定》(以下称《数据跨境流动规定》)对于免于数据合规审查的情形作出明确规定,并且明确了数据安全保障义务、数据出境的全链条全领域监管,对于数据跨境流动的规制具有重要意义。不过,前述规定均是以个人数据为规制对象,企业数据并不包含在内。个人数据,是指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息。^[1]与个人数据不同的是,企业数据是各类市场主体在生产经营活动中采集加工的不涉及个人信息和公共利益的数据。^[2]事实上,企业数据已经成为数字经济的一个关键组成部分,其潜力被广泛忽视。^[3]并且,现行法并未就企业数据出境合规问题作出专门规定,这就导致企业数据出境合规缺乏相应的规范基础,形成法律规范落后于数字技术发展的局面。

理论层面针对数据跨境流动规制的研究,主要集中于不同国家之间数据跨境管辖权的冲突^[4]、数据出境合规路径的体系协调^[5]、数据跨境流动的治理逻辑与发展趋势^[6]、比较法上数据跨境流动的规制模式^[7]、数据跨境流动的风险与防范^[8]等几个方面。然而,既有研究仍主要聚焦于个人数据跨境流动的宏观监管问题,忽视了企业数据在跨境流动问题上的特殊性。即使有少数学者注意到企业数据跨境流动监管问题,也只是主张以个人数据出境合规规则来规制企业数据的跨境流动,^[9]或抽象地指出企业数据出境需要得到主管部门批准。^[10]事实上,比较法层面已有学者指出,鉴于处理非个人数据所带来的风险,目前专门专注于对个人数据的保护的法律规定解决方案,似乎不再能够充分防范化解非个人数据处理所产生的风险。^[11]2022年12月,《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下称“数据二十条”)明确了数据分类分级的治理路径,^[12]而数据分类分级保护也在《数据跨境流动规定》中

[1] 《个保法》第4条第1款。

[2] 《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。

[3] Laura Somaini, Regulating the Dynamic Concept of Non-Personal Data in the EU: From Ownership to Portability, 6 European Data Protection Law Review 85 (2020).

[4] 冉从敬、陈贵容、王欢:《欧美跨境数据流动管辖冲突表现形式及主要解决途径研究》,《图书与情报》2020年第3期,第77-85页。

[5] 赵精武:《论数据出境评估、合同与认证规则的体系化》,《行政法学研究》2023年第1期,第78-94页。

[6] 王佳宜、王子岩:《个人数据跨境流动规则的欧美博弈及中国因应——基于双重外部性视角》,《电子政务》2022年第5期,第99-111页;唐巧盈、杨嵘均:《跨境数据流动治理的双重悖论、运演逻辑及其趋势》,《东南学术》2022年第2期,第72-83页。

[7] 金晶:《个人数据跨境传输的欧盟标准——规则建构、司法推动与范式扩张》,《欧洲研究》2021年第4期,第89-109页;洪延青:《数据跨境流动的规则碎片化及中国应对》,《行政法学研究》2022年第4期,第61-72页。

[8] 刘金瑞:《迈向数据跨境流动的全球规制:基本关切与中国方案》,《行政法学研究》2022年第4期,第73-88页。

[9] 对企业数据跨境合规适用个人数据跨境合规规则的讨论,参见李凡:《商业数据跨境流动的规范重塑及合规治理》,《中国流通经济》2023年第5期,第71-80页;张学文:《商业数据出境的规则之治:权属分析、关系构成、实践面向》,《情报杂志》2022年第2期,第176-181页。

[10] 黄现清:《数字贸易背景下我国数据跨境流动监管规则的构建路径》,《西南金融》2021年第8期,第81页。

[11] Nicoleta Chirciu & Teodor Chirvase, Non-Personal Data Processing-Why Should We Take It Personally?, 2020 European Journal of Privacy Law & Technologies 184 (2020).

[12] 《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》指出:探索数据产权结构性分置制度。建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度。

有所体现,该规定第6条第1款指出,自由贸易试验区在国家数据分类分级保护制度框架下制定数据跨境合规审查的数据清单。事实上,企业数据出境合规治理应当与个人数据出境合规治理加以区分,因为,不同类型的数据跨境流动,法律所规制的问题也有所差异。^{〔1〕}故此,在既有研究不充分的情形下,从理论上澄清企业数据出境合规规制的问题,便极为必要。

有鉴于此,本文首先通过企业数据跨境流动的合规治理现状的分析,指出我国企业数据出境面临的风险与挑战。其次,企业数据出境的合规风险,有赖于从规制理念与规制逻辑两个方面转换企业数据出境合规的治理思路进行化解。最后,依循企业数据出境合规治理的总体思路,实现企业数据出境合规分类分级治理,并强化企业数据出境合规的国际合作,以消除企业数据出境合规的障碍。

一、企业数据出境合规治理的风险与挑战

(一) 我国企业数据出境合规法律规定尚不完善

1. 企业数据出境合规规范基础欠缺时的法律漏洞

值得注意的是,虽然《个保法》第38条规定了三种数据出境的合规路径,但其只是对个人信息(或个人数据)出境的规制,并不调整企业数据出境合规问题。此外,《标准合同办法》与《认证实施规则》亦仅以个人信息出境为规制对象。与前述规定不同的是,《安全评估办法》第4条中的安全评估的对象,包括数据处理者向境外传输重要数据、关键信息基础设施运营者向境外传输个人数据、超出网信部门规定的数量向境外传输个人数据三类。并且,《数据安全法》第3条将数据界定为任何以电子或者其他方式对信息的记录。因此,从文义上看,《数据安全法》与《安全评估办法》所规定的重要数据,包含了个人数据、企业数据与公共数据。如是而言,便只有《数据安全法》与《安全评估办法》能够作为企业数据出境安全评估情形的规范基础,但也仅限于重要企业数据,而无法规制一般的企业数据,因而不具有规制范围的普遍性。故而,立法上未就企业数据出境作出专门规制,属于违反立法计划的不完善性,存在法律漏洞。^{〔2〕}

2. 准用个人数据跨境合规规则填补漏洞的局限性

立法上对企业数据出境合规问题欠缺明确的规定,存在公开型法律漏洞。在方法论层面,首先需要考虑能否通过类推适用的方式,对该公开型法律漏洞予以填补,但问题在于,此时能否类推适用个人数据出境合规规则?

类推适用个人数据出境合规规则,需要满足规范意旨与事实构成层面的相似性要求。但是,在规范目的层面,个人数据出境合规的规范意旨主要在于,在个人数据跨境传输过程中保障个人信息安全。企业数据跨境流动合规的规制目的则主要在于,在不危及数据主权安全的前提下尽可能促进企业数据跨境流动。由此可见,个人数据出境合规与企业数据出境合规的规范目的其实并不相同。

〔1〕 李思羽:《数据跨境流动规制的演进与对策》,《信息安全与通信保密》2016年第1期,第97页。

〔2〕 [德]克劳斯·卡纳里斯:《法律漏洞的确定》,杨旭译,北京大学出版社2023年版,第2页。

在事实构成层面,个人数据出境合规存在安全评估、保护认证、标准合同三种路径。首先,就安全评估而言,其适用情形为,重要数据的跨境传输、关键信息基础设施运营者跨境传输个人数据、处理个人信息数据跨境传输达到规定的数量。由于部分企业数据可能属于重要数据,因此,重要的企业数据跨境传输也存在安全评估的必要性。不过,此时企业数据跨境传输的安全评估,无论是评估的对象还是评估的内容,均与个人数据跨境传输的安全评估存在较大差异。无独有偶,个人数据保护认证、标准合同与企业数据出境合规在事实构成层面亦存在差异,无论是保护认证还是标准合同的合规路径,均是对非重要个人数据或未超出网信部门规定数量的个人数据出境的规制,但企业数据的跨境传输原则上并不考虑数据传输的数量与个人信息保护的问题。因此,企业数据出境合规与个人数据出境合规在事实构成层面也不具有相似性。

综上,在事实构成层面,企业数据出境合规与个人数据出境合规尽管存在一定的相似之处,但差异之处占据主导地位。并且,在规范目的层面,个人数据出境合规的规范目的主要是保护个人信息权益,而企业数据出境合规的规范目的主要在于促进企业数据跨境自由流动,因而,在规范目的上两者亦具有较大差异。由此,企业数据出境合规无法准用或类推适用个人数据出境合规规则。

(二) 我国企业数据出境合规面临复杂的国外政策环境

1. 国内外监管政策冲突导致合规成本增加

以美国为代表的国家对数字经济采取自由市场方式,因此,在数据跨境流动上也是采纳自由监管的思路,以此增加数据价值链的利益。^[1]事实上,《跨太平洋伙伴关系协定》(Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP)、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)、《美墨加协定》(The United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA)中的数据保护条款,一定程度上均体现了数据自由流动的价值追求。^[2]美国借助其在数字贸易领域的优势地位,一直秉持经济优先的自由贸易理念,在数据跨境流动问题上主张最大可能的跨境信息自由流动,并将自由流动作为贸易协定的一项基本原则,一方面强调个人的数字产品和服务的选择自由,另一方面则限制其他国家对数据流动的管控。^[3]美国极力推崇数据跨境自由流动,通过“长臂管辖”的方式强化对境外数据的管制,损害了其他国家的数据主权。^[4]

对于欧盟范围内企业数据跨境流动监管而言,2018年欧盟颁布了《非个人数据自由流动条例》(The Regulation on the Free Flow of Non-personal Data),从而弱化了欧盟范围内的数据本地化,消除了非个人数据在欧盟内部市场自由流动的障碍,^[5]使数据存储和其

[1] 张正怡:《数据价值链视域下数据跨境流动的规则导向及应对》,《情报杂志》2022年第7期,第78-79页。

[2] 何渊主编:《数据法学》,北京大学出版社2020年版,第172页。

[3] 许多奇:《治理跨境数据流动的贸易规则体系构建》,《行政法学研究》2022年第4期,第53-54页。

[4] 陈兵:《数字企业数据跨境流动合规治理法治化进路》,《法治研究》2023年第2期,第36-37页。

[5] Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on a Framework for the Free Flow of Non-personal Data in the European Union.

他服务更有竞争力以及实现内部市场的一体化,确保数据在欧盟内的自由流动。^{〔1〕}该条例第10条规定,欧盟内非个人数据自由流动应作为一项原则,除非为了公共安全需要特别限制或禁止。不难发现,《非个人数据自由流动条例》反对欧盟成员国的数据本地化,强调数据在欧盟范围内自由流动。在欧盟看来,数据自由流动被广泛认为是数字单一市场的关键要素之一。^{〔2〕}《非个人数据自由流动条例》限制欧盟各成员国作出数据本地化规定,确保成员国有权机关能够及时获取与使用数据,从而达到非个人数据在欧盟内部最大程度流动、利用与共享的核心目的。^{〔3〕}原则上,在欧盟范围内任何组织均可以进行企业数据的处理与传输,但是,国家监管机构应当存在适当监管的权力,即可以基于公共安全限制数据自由流动。因此,在企业数据跨境流动的监管层面,欧盟致力于缓和数据本地化的不利影响,强调企业数据在欧盟范围内自由流动,而欧盟成员国向欧盟以外的国家或地区传输数据时,则要求进行严格审查。

事实上,无论是美国的企业数据跨境自由流动规制模式,还是欧盟的企业数据跨境流动二元监管模式,均与我国企业数据跨境流动的监管模式存在一定差异。尽管我国目前没有专门的企业数据出境合规规定,但是,《数据安全法》与《安全评估办法》对重要数据(其中包含重要的企业数据)作出了规定,要求对该类企业数据的跨境流动,进行严格的安全评估。我国此种安全评估的监管模式,实际上与美国和欧盟的企业数据跨境流动监管模式均有所不同,由此导致国内外监管政策存在一定的冲突。此时,我国企业要同时面临本国与东道国的双向合规监管,并且需要根据东道国的要求提供国内相关数据,^{〔4〕}从而致使企业合规成本提升。

因此,我国企业进行数据跨境传输时,必然需要针对不同国家的合规监管规定采取不同的策略,这就容易引发数据跨境传输规则冲突。^{〔5〕}而我国企业数据跨境流动监管政策与域外监管政策的冲突,易导致我国企业进行企业数据跨境传输时,难以同时满足国内法与国外法的合规要求;若需要同时满足国内外监管政策的要求,则需要全方位了解数据接收国对于数据监管政策的特别规定,并履行烦琐的合规监管手续,同时可能需要对企业数据作进一步的技术化处理。

2. 贸易壁垒阻碍企业数据跨境自由流动

除了国内外企业数据跨境监管政策冲突增加合规成本之外,在数字贸易层面,我国企业数据出境合规还面临外国政府设置的多重贸易壁垒,这严重阻碍了企业数据的跨境自由流动。近年来,美国奉行数据霸权主义政策,对我国数字企业实施贸易歧视,致使我国数字企业境外合规面临的不确定性明显增加。^{〔6〕}尽管为推进贸易自由化,世界性与区域性的贸易合作组织规则已经建立并不断完善,但是,针对数字贸易的规定却未尽完

〔1〕 Dominic Broy, The European Commission's Proposal for a Framework for the Free Flow of Non-Personal Data in the EU, 3 European Data Protection Law Review 382 (2017).

〔2〕 Dominic Broy, The European Commission's Proposal for a Framework for the Free Flow of Non-Personal Data in the EU, 3 European Data Protection Law Review 380 (2017).

〔3〕 黄钰:《欧盟非个人数据跨境流动监管模式研究》,《情报杂志》2022年第12期,第112页。

〔4〕 许多奇:《论跨境数据流动规制企业双向合规的法治保障》,《东方法学》2020年第2期,第188页。

〔5〕 许多奇:《论跨境数据流动规制企业双向合规的法治保障》,《东方法学》2020年第2期,第188页。

〔6〕 陈兵:《数字企业数据跨境流动合规治理法治化进路》,《法治研究》2023年第2期,第39页。

备,这就导致对美国等推行霸权主义国家的制裁效果更显乏力。以美国为首的西方国家,对我国的跨国企业设置重重的贸易壁垒,甚至直接进行行政处罚。比如,我国TikTok企业就曾面临美国政府以“国家安全”为由所实施的政府封禁。

我国企业数据出境面临外国政府设置的贸易壁垒与歧视政策,这不仅与国际层面数据跨境自由流动政策相悖,而且也有违贸易自由化理念。然而,囿于主要的贸易组织对于数字贸易规定的不完善,对外国政府实施的数字贸易壁垒等行为难以有效约束,我国数字企业进行数据跨境流动面临更为严苛的审查,这严重阻碍了我国企业数据的跨境自由流动。

二、企业数据出境合规规制的基本理路

(一) 规制理念:企业数据出境合规治理的基本理念

1. 私法自治:以缔结合同的方式实现数据跨境自由流动

《数据跨境流动规定》第3条强调,在国际贸易活动中进行数据跨境传输,不包含个人信息或者重要数据的,无须进行合规审查。从该条规定不难看出,企业数据一般不包含个人数据与重要数据,因此,对于企业数据的出境,无须以个人数据或重要数据出境合规规则对其进行合规审查,这实际上体现了促进企业数据跨境自由流动的理念。而企业数据跨境自由流动,本质上是企业数据传输主体意思自治的结果。

企业数据出境合规,实际上需要处理好自由与秩序、规则与规则、利益与利益的多层次冲突。^{〔1〕}企业数据作为企业的责任财产,原则上只可能涉及商业秘密、知识产权或不正当竞争。而重要数据的国家安全性与个人数据的可识别性,决定了重要数据跨境传输时必须考虑对国家安全的影响,个人数据跨境传输时必须考虑对人格利益的影响。但企业数据出境,一般不会影响人格利益或国家安全,此时,也就无须以严格的合规审查程序限制其自由流动,因此,允许数据传输者与数据接收者以缔结合同的方式进行企业数据跨境传输,能够充分尊重私主体的意思自治。

在私法自治的理念下,只要数据传输企业与数据接收企业通过要约—承诺的方式就数据传输达成合意,该企业数据跨境传输合同便应当得到尊重,从而,基于合法有效的合同,不同国家之间的企业便可以实现企业数据的自由传输。由此可见,企业数据跨境自由流动本质上是私主体意思自治的结果,政府部门原则上不应当直接介入企业数据的传输过程,否则构成对私法自治的不当干预。

依此而言,尽管在允许数据自由流动和维护国家管辖权之间的权衡变得很明显,^{〔2〕}但是,在不危及国家安全与公共利益的前提下,数据自由流动应当作为基础性原则。^{〔3〕}而企业数据跨境自由流动,本质来源于数据传输主体的意思自治,基于合法有效的数

〔1〕 叶进芬:《WTO法框架下数字产品跨境交易规则研究》,中国原子能出版社2022年版,第99-101页。

〔2〕 Mira Burri, Data Flows and Global Trade Law, in Mira Burri (ed.), Big Data and Global Trade Law 11 (Cambridge University Press 2021).

〔3〕 马长山主编:《数字法治概论》,法律出版社2022年版,第196-197页。

据传输合同,可以实现企业数据在不同国家之间的自由传输。因而,在充分尊重私主体意思自治的情况下,不应拘泥于企业数据的本地化存储,而应当允许其跨境自由流动。否则,对数据流动设置障碍可能直接影响贸易,并可能危及创新数字经济的实现。^{〔1〕}一方面,数据跨境流动有助于企业优化全球要素资源配置;另一方面,数据跨境流动有利于促进全球范围内的科技与理念创新。^{〔2〕}

2. 公法管制:数据跨境自由流动的边界与限度

不过,在坚持促进企业数据跨境自由流动的同时,需要注意到,企业数据的跨境传输,不仅涉及数据传输方与数据接收方跨境贸易的私法关系,还可能涉及主权国家之间的数据主权安全保障的公法管制关系。因为,信息具有经济价值,存储和处理某些类型数据的能力会增强一个国家的技术优势,但在此方面处于弱势的国家则面临国家主权遭受侵害的风险。^{〔3〕}事实上,数据主权是国家主权在数据领域的延伸,国家之间的利益博弈也体现在数据跨境流动监管上。^{〔4〕}在数据主权的视角下,如何协调数据跨境流动与本国数据主权完整之间的冲突便存在问题,因为,数据主权在数据跨境流动过程中可能会受到侵害。^{〔5〕}以滴滴出行案为例,国家网信办明确指出了滴滴出行的16项违法事实,认为其存在违法收集、过度收集用户个人信息,并且,信息收集的过程中,未尽到告知义务与获得用户的明确同意。更为严重的是,滴滴出行向境外传输了不应公开的严重影响国家关键信息基础设施安全与数据安全的重要数据。由此可见,滴滴出行被罚本质上是因为违法收集并公开个人数据与重要数据,并且,个人数据与重要数据均未经过技术化处理,违法披露这些数据就意味着不仅侵害用户的个人信息安全,而且可能危及国家数据安全。故而,企业数据跨境传输不是纯粹的企业之间商事交易的私法自治问题,更有可能涉及个人信息安全与国家数据主权安全,在这个意义上,企业数据跨境自由流动就需要进行一定的限制。

尽管现在的数据在贸易政策讨论中特别突出,但学者已经将数据流动和保护国家利益的需要联系起来。^{〔6〕}数据跨境流动为国际贸易的发展提供了极大便利,但也可能对国家安全、个人隐私等产生不利影响。^{〔7〕}不可否认,跨境数据流动与国家数据主权、个人信息安全、公共安全等安全风险是紧密关联的。^{〔8〕}关于数据跨境自由流动中的公法管制的必要性,CPTPP也强调缔约方为实现“合法公共政策目标”,可以采取不一致的措施,但措施须符合比例原则。^{〔9〕}

因此,对于企业数据跨境自由流动的管制,允许出于公共政策的目的设置例外情

〔1〕 Mira Burri, Data Flows and Global Trade Law, in Mira Burri (ed.), Big Data and Global Trade Law 13 (Cambridge University Press 2021).

〔2〕 唐巧盈、杨嵘均:《跨境数据流动治理的双重悖论、运演逻辑及其趋势》,《东南学术》2022年第2期,第73-74页。

〔3〕 Maria Tzanou, The Fundamental Right to Data Protection 15 (Hart Publishing 2017).

〔4〕 陈兵:《数字企业数据跨境流动合规治理法治化进路》,《法治研究》2023年第2期,第35页。

〔5〕 王金照、李广乾等:《跨境数据流动:战略与政策》,中国发展出版社2020年版,第51页。

〔6〕 Mira Burri, The Governance of Data and Data Flows in Trade Agreements: The Pitfalls of Legal Adaptation, 51 U.C. Davis Law Review 69 (2017).

〔7〕 宋瑞琛、冯纯纯:《中美数据跨境流动的国际法规制及中国的因应》,《国际贸易》2022年第7期,第89-96页。

〔8〕 徐拥军、王兴广:《总体国家安全观下的跨境数据流动安全治理研究》,《图书情报知识》2023年第6期,第22页。

〔9〕 范晓宇:《数据秩序的法律治理》,法律出版社2022年版,第247-248页。

形,以协调数据自由流动与域内监管政策之间的矛盾,但对于公共政策例外限制,则可以通过制定负面清单的方式实现。^{〔1〕}对于危及国家数据主权安全的企业数据,不得允许其自由流动。在此意义上,尽管出于对私法自治的尊重,应当尽可能促进企业数据跨境自由流动,但是,从公法管制的视角来看,出于公共安全目的可以对数据自由流动进行限制,^{〔2〕}即企业数据出境自由流动不得损害国家数据主权安全。因此,在企业数据跨境传输可能危及国家数据主权安全的情况下,政府部门有权主动介入,对企业数据跨境传输进行安全评估与认证,若企业数据跨境传输会直接影响国家数据主权安全,则政府部门可以以公共安全为由禁止企业进行数据跨境传输,数据传输主体所缔结的合同也应归于无效。

由是观之,企业数据出境合规的规制理念,体现为自由与秩序的利益衡量。在私法自治层面,应当坚持当事人以缔结合同的方式实现企业数据跨境自由流动,以促进数字经济的发展;在公法管制层面,应当在企业数据跨境流动的过程中,保障国家数据主权安全,即实现企业数据跨境安全前提下的自由流动。

(二) 规制逻辑:企业数据出境合规治理的逻辑进路

1. 技术逻辑视角:企业数据与个人数据、公共数据剥离

企业数据往往以数据集的方式存在,由此导致企业数据的规则建构,需要通过技术手段剥离企业数据与个人数据、公共数据。^{〔3〕}“数据二十条”虽然肯认了数据分类分级治理的正当性,但是,并未从技术与法律层面对数据分类分级作出具体规定。事实上,绝大部分的企业数据主要来源于个人数据,少部分源于公共数据,在经过技术处理后,方能成为独立的企业数据,进行数据跨境流动。故而,对于企业数据出境合规治理,需从技术层面将企业数据与个人数据或公共数据进行剥离。

企业数据从个人数据中剥离,主要是通过个人数据的匿名化或去识别化的方式实现。个人数据以信息为内容,以数据为载体,个人数据主体享有人格利益,而个人数据处理者则享有财产利益。个人数据的核心在于,具有主体身份的识别功能。^{〔4〕}《个保法》第51条第3项规定了加密、去标识化等安全技术措施,通过这两种去除个人特别标识的手段,人格利益部分从该数据中剥离,处理后的数据无法与特定的自然人进行关联,不会对数据主体的人格利益造成损害,然后再将大量的数据进行分析处理,成为独立于个人数据的企业数据集,由此,企业可以对其进行商业化利用,包括企业数据的跨境传输。

企业数据从公共数据中剥离,则是通过公共数据脱敏化处理的方式实现。公共数据系政府等公共部门在履行公共职能过程中获取的数据,产生于国家财政资金,具有社会共享的公共属性。^{〔5〕}对于公共数据而言,可以区分为一般的公共数据与重要的公共数据。对于重要的公共数据,即关涉国家安全的公共数据,应当禁止向境外传输。但对于一般的公共数据而言,可能涉及企业的商业秘密或个人隐私,此时,应当对公共数据进

〔1〕 叶进芬:《WTO法框架下数字产品跨境交易规则研究》,中国原子能出版社2022年版,第102-103页。

〔2〕 Dominic Broy, The European Commission's Proposal for a Framework for the Free Flow of Non-Personal Data in the EU, 3 European Data Protection Law Review 382 (2017).

〔3〕 张学文:《商业数据出境的规则之治:权属分析、关系构成、实践面向》,《情报杂志》2022年第2期,第180页。

〔4〕 《欧盟一般数据保护条例》第4条第1项。

〔5〕 姜伟、龙卫球主编:《数字法学原理》,人民法院出版社2023年版,第324页。

行脱敏化处理,即通过算法变形、访问控制、行为授权的方式降低数据的敏感程度,^[1]便可以将公共数据的公共性部分祛除,此时,不会对公共利益造成损害。而公共数据经过数据的脱敏化与组合加工的方式成为企业数据集合,企业便可以对其进行商业化利用,并进行数据跨境传输。

2. 法律逻辑视角:企业数据的合理确权与分类分级治理

(1) 企业数据确权的必要性及确权路径

事实上,欲实现企业数据跨境自由流动,在法律层面,首先需要对企业数据进行合理确权,理由在于:第一,从财产流转的基本逻辑来看,企业数据作为财产权客体的地位已经获得民法典的承认,且其仍然应当遵循权利归属、转让的基本逻辑,即归属明晰方能合理流转,否则容易引发权属纠纷。在物权法层面,物权的归属乃物权转让的前提,未明晰动产或不动产权属状态,可能会对物权变动的效力产生影响,阻碍财产的流转。虽然企业数据不属于物权的客体,且企业数据具有可复制性,但是,享有企业数据的复制权,并不代表其取得了该企业数据的排他性权利,而只是获得了数据的使用权。^[2]在这个意义上,只要企业数据进行流转,就无法回避权属的确定问题。不过,有学者认为,可以直接跳过数据确权环节对数据处理关系进行规制,因为数据确权的目的在于,有效保护和激励各方主体的相关权益,平衡利益诉求,数据确权本质上保护的应当是数据权益,而非企业对数据的占有权。^[3]但事实上,企业数据确权并不等同于赋予商业主体对数据的所有权,对权利或利益的控制与支配并不都以所有权的方式呈现,也可以对财产性权利进行事实支配成立准占有,^[4]从而具备有限排他性。故越过权属界定,难以实现权利保护,也无法实现企业数据的跨境流动。事实上,数据治理体系包括数据确权规则与数据流通规则,^[5]且目前我国正试点建立数据产权登记制度,这也进一步说明数据确权的必要性。

第二,从企业数据的形成过程来看,洛克财产权劳动理论进一步证明企业数据权属界定与劳动激励之间的紧密关联。不难发现,数据处理者以匿名化和脱敏化技术,对相关数据进行分析整理,获得企业数据集合,这一过程存在大量的劳动付出,而企业数据集合的财产价值正来源于此。洛克劳动财产理论早已指出,任何人只要使客观物体脱离原本的自然状态,就赋予了特定的劳动,因而使其成为他的财产。^[6]换言之,在自然状态下,财产属于一切人共有,而个人基于对自己身体的所有权对特定客体付诸劳动,使得该部分财产脱离共有而成为其私有财产,并且,财产私有应当以生存和发展需求为限度。^[7]因此,劳动实现了财产共有到财产私有的转变。而财产权本身,便指劳动者对其劳动创造的价值所享有的权利。^[8]就企业数据集合的生产与劳动而言,商业主体通过算

[1] 张学文:《商业数据出境的规则之治:权属分析、关系构成、实践面向》,《情报杂志》2022年第2期,第180页。

[2] [德]康德:《法的形而上学原理》,沈叔平译,商务印书馆1991年版,第86页。

[3] 唐要家:《数据产权的经济分析》,《社会科学辑刊》2021年第1期,第102页。

[4] 史尚宽:《物权法论》,中国政法大学出版社2000年版,第604页。

[5] 范晓宇:《数据秩序的法律治理》,法律出版社2022年版,第55页。

[6] [英]洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆1996年版,第19页。

[7] [美]罗伯特·P.墨杰斯等:《新技术时代的知识产权法》,齐筠等译,中国政法大学出版社2003年版,第2页。

[8] [法]弗雷德里克·巴斯夏:《财产、法律与政府》,秋风译,商务印书馆2012年版,第141页。

法程序,将单个的数据进行组合,使得大量的数据转换为企业数据集合,此时商业主体赋予了企业数据集合独特的财产价值,这在一定程度上决定了企业数据权属取得与归属,从而能够对积极投入劳动的数据处理者予以经济激励。

依此,企业数据确权存在逻辑与价值的双重正当性,在逻辑层面,企业数据合理确权是企业数据跨境流动的前提;在价值层面,依据洛克劳动财产理论,企业数据的合理确权与劳动激励相连。因此,企业数据权属的确定具有正当性与必要性。

在证成企业数据合理确权的正当性与必要性的基础之上,需要进一步予以回应的是,如何对企业数据权属进行合理界定?对此,有学者提出,传统所有权的权利分离理论无法妥当解释数据界权,应当以“权利束”理论为数据提供保护。^{〔1〕}还有学者主张,“权利束”的分散结构可能导致数据的适用不足,建议改造为“权利树”,主干为合同范围内的数据支配权,涉及国家安全与公共利益时,辅之以强制使用许可。^{〔2〕}然而,尽管“权利束”或“权利树”理论具有一定的合理性,但其仍然是经济学上“产权”这一权利束的概念转化,可能无法应对多样化的数据确权场景,存在无法弥合的局限。也有学者主张,应当在知识产权制度基础上建立以数据产权为核心的路径对企业数据进行确权。^{〔3〕}不过,知识产权保护需要证明某种程度的新颖性或原创性,^{〔4〕}并非所有的企业数据集合都具有独创性,对于不具备独创性的企业数据集合无法赋予其知识产权,且知识产权只是对数据集合的结构进行保护,而不对数据内容本身进行保护。由此可见,以知识产权对企业数据确权也不合理。也有观点提出,企业数据权益更适合采纳场景化的保护进路。^{〔5〕}具体而言,数据权属界定的考量因素包含数据隐私保护,促进数据共享与互联互通,根据爬虫平台与被爬虫平台的性质、爬虫行为的特征等因素确立不正当竞争与合理使用的边界。^{〔6〕}但需要注意的是,此时的考量实际上是针对个人数据,而且仍然没有跳出所有权的逻辑固化的藩篱。

值得注意的是,“数据二十条”已明确指出,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权的“三权分置”。故而,企业数据确权也应当在产权结构性分置的构造下进行,而不应当遵循所有权(或支配权)的确权逻辑。准此,企业数据权属界定实际上可以具体化为数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权的权利界定,这三种数据权利的界定需要在场景化下进行考量:其一,原始数据主体与数据处理者之间的约定,即对于企业数据的权属,存在私法自治的空间,当事人可自行约定;其二,根据企业数据生产、流通、使用过程中各主体投入的劳动和其他贡献,分别界定商业主体的数据持有、使用、获取收益的权益;其三,公共利益可以作为企业数据权属的限制性因素,即公共利益的保障应当优先考量。

〔1〕 王利明:《论数据权益:以“权利束”为视角》,《政治与法律》2022年第7期,第104页。

〔2〕 谢鸿飞:《财产权的公共性》,《上海政法学院学报(法治论丛)》2022年第5期,第16页。

〔3〕 冯晓青:《知识产权视野下商业数据保护研究》,《比较法研究》2022年第5期,第41页。

〔4〕 Laura Somaini, Regulating the Dynamic Concept of Non-Personal Data in the EU: From Ownership to Portability, 6 European Data Protection Law Review 86 (2020).

〔5〕 马长山主编:《数字法治概论》,法律出版社2022年版,第154页。

〔6〕 马长山主编:《数字法治概论》,法律出版社2022年版,第155页。

（2）企业数据出境合规分类分级治理的必要性

尽管数据传输的自由流动可能带来好处，但近几十年来，各国倾向于实施更严格的法规，以限制数据的自由流动，大多数法规对个人数据和非个人数据施加了不同程度的限制，一些国家更进一步，采取不同的数据分类，以确定保护所需的基线安全控制，然而，数据的标准和分类可能在不同的司法管辖区有所不同，导致应用和理解的不一致。^{〔1〕}“数据二十条”确立了数据分类分级的治理思路，即区分企业数据、个人数据、公共数据，并按照数据的不同级别进行区分保护。企业数据出境合规分类分级治理的意义主要在于，采取不同的具体措施对数据处理活动予以规制，避免同质化保护影响保护效率与数据价值。^{〔2〕}

对于企业数据出境而言，同样需要进行分类分级规制。数据分类是一种横向的区分，而数据分级则是一种纵向的区分。^{〔3〕}就企业数据的类型而言，可以按照企业数据的来源、应用场景等标准进行区分，详言之，依据数据来源可以分为内部企业数据与外部企业数据；依据数据阶段可以分为原始企业数据与衍生企业数据；依据是否可以技术剥离可以分为可剥离的企业数据与不可剥离的企业数据。对于企业数据的分级而言，依据重要性程度可以分为一般的企业数据与重要的企业数据。不过，在对企业数据出境合规进行分类分级治理的过程中，企业数据的分类与分级存在交叉的可能，因为，数据的级别实际上是对不同数据类型的重要性与危害性的评价。我们认为，依据“数据二十条”所确立的个人数据、公共数据、企业数据的类型区分思路，在企业数据的分类标准上，应当以企业数据是否可以与个人数据或公共数据进行剥离为分类标准，将数据分为可剥离的企业数据与不可剥离的企业数据，并建立不同的合规治理规则。

三、企业数据出境合规分类分级治理的制度实现

（一）可剥离的企业数据出境的合规治理

1. 一般的企业数据的跨境传输：自由流动与合同备案

在对数据集合进行匿名化或脱敏技术处理的基础上，企业数据得以成为纯粹的商业主体的责任财产。在数字贸易中，原则上，只要无碍于个人人格利益与公共利益的保护，企业数据跨境传输的当事人就可以直接签订合同进行数据跨境传输，在合同中约定数据跨境传输过程中的数据保护义务以及违反义务时的责任承担，而无须公权力机关的介入。对此，规范层面也作出了肯定，新近生效的《数据跨境流动规定》第3条明确指出，国际贸易中产生的数据向境外提供，不包含个人信息或者重要数据的，就无须以安全评估、保护认证、缔结标准合同的方式进行数据跨境传输。对此，似乎可以理解为，在企业数据能够与个人数据或公共数据进行剥离的情形下，无须依照个人数据出境合规

〔1〕 Linxin Dai, A Survey of Cross-Border Data Transfer Regulations through the Lens of the International Trade Law Regime, 52 New York University Journal of International Law and Politics 956 (2020).

〔2〕 吴卫明编著：《数据合规法律实务》，法律出版社2022年版，第70页。

〔3〕 张丽、孙菲阳主编：《跨境数据流动：全球治理趋势与我国规制策略》，电子工业出版社2022年版，第197页。

规则进行合规审查,而应促进企业数据出境合规下的自由流动。

不过,对于一般的企业数据而言,即使其具有典型的财产属性而允许其跨境自由流动,也不意味着当事人可以借助缔结合同的方式随意传输企业数据而无须受到任何的行政监管。事实上,在企业数据跨境自由流动时,仍然需要对其进行备案管理,而该备案管理程序,应当以数据传输方与数据接收方所缔结的合同为对象。此种备案系事后备案而非事前备案,以满足企业数据跨境自由流动的要求。

2.重要的企业数据的跨境传输:事前评估与动态监管

所谓重要数据,是指与国家安全、经济发展,以及社会公共利益密切相关的数据,这些数据一旦泄露,可能直接影响国家安全,重要数据的范畴不限于个人信息,但个人信息中有可能涉及重要数据。^{〔1〕}因此,在数据分类分级的框架下,数据类型与数据级别存在着交叉的可能,无论是个人数据、公共数据还是企业数据,在数据级别上均可以区分为一般数据与重要数据。

虽然企业数据原则上仅具有财产属性,应当促进其跨境自由流动。但是,若该企业数据地位比较重要,一旦跨境传输,可能有损国家安全,则该类企业数据属于重要的企业数据,此时,该类企业数据不能自由跨境流动,而应当对其进行严格限制,甚至是禁止商业主体将该类企业数据向境外传输。

不过,即使是在限制传输的情形下,也应当对该类企业数据进行严格的审查。从行政法的角度来看,对该类企业数据出境的审查许可属于具体行政行为中的行政许可,此时,应当进行出境安全评估。依据《数据安全法》第30条第2款之规定,风险评估报告应当包括处理的重要数据的种类数量、开展数据处理活动的情况,面临的数据安全风险及其应对措施等。只有在通过相关部门的安全评估后,该类企业数据方能进行跨境传输。由于数据跨境安全评估程序作为重要的企业数据跨境传输的前置许可程序,未经安全评估及许可进行数据传输的,需要承担违法传输数据的行政责任。

对于重要的企业数据出境合规监管,除了需要在数据出境之前进行事前安全评估之外,还需要对其传输过程进行持续监管。《数据跨境流动规定》第12条明确指出,各地网信部门应当强化事前事中事后全链条全领域监管。由此可见,在规范层面,事实上已经确立了事前事中事后动态监管的思路。之所以强化数据跨境流动的动态监管,是因为技术的负外部性使得数据剥离产生反推复原的风险。^{〔2〕}因此,对于重要的企业数据跨境传输,不仅应当进行严格的事前安全评估,而且,需要对传输过程进行监督,避免在算法反推的情形下,复原原始的核心机密部分,影响我国数据安全。

(二)无法剥离的企业数据集合出境的合规治理

1.企业数据与个人数据混合的数据集合:准用个人数据出境合规规则

虽然在绝大多数情形下,数据集合中的企业数据可以进行剥离,但不可否认的是,有的数据集合无法通过脱敏与匿名化处理的方式,将个人数据、公共数据分离出来。因

〔1〕 何渊主编:《数据法学》,北京大学出版社2020年版,第55页。

〔2〕 张学文:《商业数据出境的规则之治:权属分析、关系构成、实践面向》,《情报杂志》2022年第2期,第181页。

而,商业主体在进行数据跨境传输时,若该数据集合包含了大量的个人数据,并以现有技术水平无法通过匿名化的方式祛除个人身份识别的部分,一旦允许商业主体将该类数据自由传输至境外,则可能严重损害个人信息安全。

此时,由于无法将企业数据从个人数据中剥离,自然不可能单独适用企业数据出境合规规则。在欧盟,对于同时包含个人数据和非个人数据的数据集合,《非个人数据自由流动条例》适用于该数据集合的非个人数据部分;如果数据集合中个人数据和非个人数据无法分离,本条例不应影响欧盟第2016/679号条例的适用。^{〔1〕}换言之,在数据集中个人数据与企业数据无法分离时,在数据跨境传输的过程中,仍然适用个人信息保护的相关规定。

在现有技术手段下,若无法对个人数据进行匿名化处理,则对于该数据集合而言,仍然应当适用个人数据出境合规审查程序,即可以适用安全评估、保护认证、标准合同的相关规则。^{〔2〕}原因在于,无法将个人数据剥离的数据集合,尽管其具备财产属性,但是,其仍主要体现为人格属性,且在价值位阶上具有保护的优先性。故而,企业数据与个人数据混合的数据集合,应当准用个人数据出境合规规则,即应当按照安全评估、保护认证、标准合同的具体程序进行合规审查。若属于重要数据、关键信息基础设施运营者传输数据或超出规定的传输数量,则必须进行安全评估,除此之外,当事人可以选择标准合同或保护认证的方式完成合规审查程序。

2.企业数据与公共数据混合的数据集合:准用重要数据出境合规规则

若无法通过现有技术对公共数据进行脱敏化处理,则该数据集合无法剥离成为企业数据,此时,不能因为其包含了财产价值就允许其自由流动。事实上,在企业数据与公共数据无法进行技术剥离的情况下,其仍主要体现为公共数据的公共属性,若无法将公共数据剥离,而直接向境外进行数据传输,则会严重危及数据主权安全,即便该数据集合具有一定的商业价值,数据处理者也不得在未剥离公共数据的情况下,贸然进行数据集合的跨境传输,否则,有可能承担相应的法律责任。

因此,公共数据在级别上与重要数据具有类似性,其跨境传输有可能直接危及国家数据安全和公共利益,在法律规则层面,应当将该类数据归入重要数据的范围。此时,需要将无法对公共数据剥离的数据集合拟制为重要数据,在跨境传输的合规审查问题上,同样需要进行全周期监管,即跨境传输之前进行安全评估,同时,对跨境传输的过程进行监管,防止以算法推演的方式还原重要数据的敏感部分。

四、企业数据出境合规分类分级治理的国际保障

在全球化的背景下,以数据跨境传输为形式的跨境数字贸易不再只是涉及数据输出国与数据输入国的关系,而是关联全球范围内的数据跨境传输关系。而企业数据跨境自由流动,必然需要各国合规政策的协调方能实现。基于国际法上国际性公约与双边

〔1〕 欧盟《非个人数据自由流动条例》第2条。

〔2〕 李凡:《商业数据跨境流动的规范重塑及合规治理》,《中国流通经济》2023年第5期,第74页。

协定的理论分类,企业数据出境合规的国际合作治理就需要从多边与双边的视角展开。就国际性公约而言,由于数据传输本质上是一种数字贸易形式,故应当以调整世界贸易关系的WTO为中心,推动缔结企业数据跨境流动合规的国际条约;就双边协定而言,应当以我国为中心,依托“一带一路”的制度优势,缔结企业数据跨境合规的双边投资协定。

(一) 推动缔结WTO范围内企业数据跨境流动合规的国际条约

数据跨境流动具有天然的全球属性,构建数据跨境流动规则体系必须立足全球视野,在数据跨境流动规则领域进行深度的国际合作。^[1]在比较法层面,各国对于企业数据出境合规的规制模式的差异,影响企业数据在全球范围内的有序流动,严重阻碍了跨境数字贸易的发展。

目前,WTO通过推动通信技术服务和信息技术产品的贸易自由化促进了跨境数据流动,在通信技术服务层面,《服务与贸易总协定》框架下有《基础电信协议》和《关于电信服务的附件》,《基础电信协议》要求WTO成员在客观公正的基础上非歧视地向其他成员开放国内的基础电信服务市场,而《关于电信服务的附件》要求所有WTO成员保证以合理和非歧视的条款和条件接入和使用其公共电信传输网络和服务;在信息技术产品层面,《信息技术协定》坚持在最惠国待遇原则的基础上适用于所有成员,每个成员都可以从《信息技术协定》缔约方的市场准入承诺中受益。^[2]

在此基础上,我国应当积极参与国际规则的制定,大力开展国际合作,争取做国际规则制定的构建者,^[3]构建符合我国利益的国际规则。一方面,我国应当以WTO为平台,在成员范围内,推动企业数据跨境流动合规的国际性标准的建立;另一方面,促进WTO企业数据跨境流动规则与内国法的协调与衔接。

首先,企业数据跨境流动合规的国际标准的设立,应当通过WTO签署国际条约的方式实现。其合理性在于:其一,在WTO法框架下,数据跨境流动主要以数字产品跨境交易的方式实现,在货物贸易中,GATT确立了数据自由流动制度,在服务贸易中,GATS的一般规定为数据自由流动提供了良性竞争环境;^[4]其二,因为WTO本身存在一套关于商品、服务和知识产权保护的严格和可执行的规则,^[5]并且,签署国际性条约,具有较强的拘束力,有别于国际组织所作出的不具有法律拘束力的决议、宣言等国际软法。^[6]因此,为弥合各国企业数据跨境流动合规标准的差异,有必要以WTO为平台,在WTO的组织议事规则下,集中针对企业数据跨境流动合规标准差异之处进行平等磋商,初步形成并签署企业数据跨境流动合规的国际条约。

其次,对于签署的WTO企业数据跨境流动合规的国际条约,应当进一步明确其在

[1] 张丽、孙菲阳主编:《跨境数据流动:全球治理趋势与我国规制策略》,电子工业出版社2022年版,第208页。

[2] 谭观福:《数字贸易中跨境数据流动的国际法规制》,《比较法研究》2022年第3期,第173页。

[3] 许多奇:《个人数据跨境流动规制的国际格局及中国应对》,《法学论坛》2018年第3期,第137页。

[4] 叶进芬:《WTO法框架下数字产品跨境交易规则研究》,中国原子能出版社2022年版,第80-83页。

[5] Mira Burri, Data Flows and Global Trade Law, in Mira Burri (ed.), Big Data and Global Trade Law 15 (Cambridge University Press 2021).

[6] 何志鹏:《国际法要论》,北京大学出版社2023年版,第66页。

国内的适用,这主要涉及两个问题:一是条约的转化与并入问题;二是条约与国内立法冲突时的处理问题。^{〔1〕}我国仅在立法明确规定可直接适用某条约时,方可通过并入的方式适用该条约,否则,便只能通过制定国内法的方式,将条约内容转化为国内法。最高人民法院亦明确指出,人民法院应当依据法律、行政法规以及地方性法规审理国际贸易行政案件。如此而言,对于签署的WTO企业数据跨境流动合规国际条约,不能直接适用,而应当通过制定国内法的方式,将相关条约的内容进行转化适用。此外,针对WTO企业数据跨境流动合规国际条约与国内法的冲突,我国可以在签署国际条约时,基于公共政策对特定条款提出保留,并且,若无法律明文规定应当优先适用WTO国际条约的内容,则此时只能适用国内法的规定。在推动构建WTO企业数据跨境流动合规国际条约时,需要尽可能将相关内容转化为国内企业数据跨境流动合规规则,以减少与国际条约之间的冲突,促进企业数据跨境自由流动。

不过,借助WTO平台签订国际条约,以减少企业数据跨境流动合规的监管政策冲突也存在一定的障碍:其一,目前唯一在数字贸易领域推进多边规则制定的是2019年1月开始的WTO电子商务诸边谈判,但因数字经济谈判牵涉各方利益,各成员间数字经济发展不平衡,故而针对数据本地化措施收益较少。事实上,无差别地禁止数据本地化,实现完全的企业数据跨境流动,可能会威胁数字贸易中国家的发展权,使得基于WTO达成企业数据跨境流动合规的国际条约难以实现。^{〔2〕}其二,全球性的数据跨境流动规则并不明确,WTO协定适用于各国数据跨境流动措施时陷入难以判定其是否合规的困境。^{〔3〕}换言之,目前WTO关于数据跨境流动合规的规则阙如,且相关联的规则也不够具体明确,对于调整企业数据跨境流动的合规问题缺乏针对性,因此,在具体的企业数据跨境传输的情形下,无法依据清晰明确的标准判断企业数据跨境传输是否合规。这些障碍的消除,有赖于将来进一步制定WTO国际条约时,充分考虑数据本地化的例外保留与合规标准的具体化。

(二) 依托“一带一路”缔结企业数据跨境流动合规的双边投资协定

事实上,除了通过国际条约消除各国企业数据跨境流动合规规则的冲突之外,我国还应当立足于本国国情,以“一带一路”为基点,与沿线国家建立企业数据跨境流动合规的双边合作机制。此种双边合作机制体现为,就企业数据跨境流动合规监管问题,在双边投资协定中进行规制,从而进一步消除跨境数字贸易的数字鸿沟与合规壁垒。

我国与“一带一路”沿线国家的投资合作日益紧密,但也伴随着投资争端,企业数据跨境流动合规的冲突即为典型的贸易争端。^{〔4〕}而通过双边互认机制的建立,可以实现与“一带一路”沿线国家之间的企业数据跨境流动合规标准的相对一致化。此种做法在GATS第7条亦有所体现,其确立了国家之间相互承认服务提供者获得授权、许可或证明

〔1〕 车丕照:《国际经济法研究》,法律出版社2015年版,第62页。

〔2〕 张渝:《数据本地化措施兴起下国际投资保护规则的适用困境及其纾解》,《武大国际法评论》2021年第4期,第155页。

〔3〕 郭德香:《晚近经贸协定对数据跨境流动的规制及中国因应》,《武大国际法评论》2023年第1期,第75页。

〔4〕 殷敏、王珍珍:《一带一路争端解决机制:理论与法规》,上海人民出版社2020年版,第71页。

的标准或准则的机制,不过,此种针对特定国家的承认协议,不得构成对同等条件的其他国家的歧视。^{〔1〕}此种针对企业数据跨境流动合规的互认机制,有别于以WTO为基础建立的企业数据跨境流动合规的国际公约,互认机制往往针对特定两个国家之间,因此,其本质上属于双边协定。

企业数据跨境流动合规的双边互认机制,实际上可以通过我国与其他国家签署双边投资协定的方式建立。由于企业数据跨境传输是跨境贸易的重要形式,而我国与其他国家之间往往存在双边投资协定。双边投资协定的签订与实施促进了中国企业对“一带一路”沿线国家的直接投资。^{〔2〕}在双边投资协定层面,我国可选择优先与参与“一带一路”建设的国家进行合作,因我国与这些国家在投资、能源等领域存在一定的合作基础,与之在数据传输方面进行合作及对话从效率与深度上分析都具有一定的优势,相关国家可以成为我国积极签订双边数据跨境传输协议的突破口。^{〔3〕}因此,针对企业数据跨境流动的合规监管分歧,以“一带一路”为媒介,建立并强化与“一带一路”沿线国家的双边合作,尤其是缔结双边投资协定,在协定中针对企业数据跨境流动的合规问题进行磋商,并在最大程度上达成一致意见,以最小的成本实现企业数据跨境自由流动,助力数字贸易的发展。在这个意义上,可以通过与周边国家签订双边投资协定的方式,减少企业数据跨境流动监管政策冲突的负面效应。

准此,可以与“一带一路”沿线国家缔结双边投资协定,并在协定中消除或减少企业数据跨境流动监管的分歧,进一步简化企业数据跨境流动的合规审查程序。与此同时,不得进行任意和不合理的歧视,在双边投资协定的构建中,应当允许第三国以同等条件加入。充分发挥“一带一路”的政策效应,进一步促进以企业数据跨境流动为主要形式的数字贸易的发展。

五、结语

随着全球化程度的日益加深,数据跨境流动在数字贸易发展中的地位举足轻重。我国企业数据出境合规面临国内法律规定不完善、国外政策环境日趋复杂的风险。对此,须构建独立于个人数据的企业数据出境合规规则,并强化国际合作。企业数据出境合规规则建构的总体思路为,在规制理念层面,坚持安全流动前提下的企业数据跨境自由流动;在规制逻辑层面,技术上将企业数据与个人数据、公共数据加以剥离,法律上对企业数据进行合理确权及分类分级治理。依循前述之规制思路,一方面,应将跨境企业数据类型化为可剥离的企业数据与不可剥离企业数据的数据集合,并依照数据级别进行区分规制。具体而言,对于可剥离的企业数据而言,若为一般的企业数据,则应在企业数据跨境自由流动的同时进行合同备案;若属于重要的企业数据,则应在企业数据出境前进行安全评估,并对企业数据跨境传输过程与结果进行全周期动态监管。对于不可剥离企业数据的数据集合,若该数据集合包含个人数据且无法剥离,则应当准用个人数据出

〔1〕 谭观福:《数字贸易中跨境数据流动的国际法规制》,《比较法研究》2022年第3期,第172页。

〔2〕 王丽丽、范志勇:《双边投资协定与“一带一路”沿线国家的市场进入》,《浙江学刊》2017年第6期,第156页。

〔3〕 梅傲:《数据跨境传输规则的新发展与中国因应》,《法商研究》2023年第4期,第70页。

境合规规则；若该数据集合包含公共数据，则应当将其拟制为重要数据，准用重要数据出境合规规则。另一方面，应当推动 WTO 成员在平等磋商的基础上，签署企业数据跨境流动合规的国际条约；同时，依托“一带一路”，缔结企业数据跨境流动合规的双边投资协定，以此，为我国企业数据出境合规提供国际保障。

Compliance Dilemma and Optimization Path of Cross-border Flow of Enterprise Data

HUANG Qingxin

Abstract: In cross-border digital trade, Chinese enterprises face risks of non-compliance governance due to inadequate domestic legal systems and increasingly complex foreign policy environments. The reasonable relief path lies in establishing independent compliance rules for enterprise data outbound, separate from personal data, and strengthening international cooperation. The overall train of thought for regulating enterprise data outbound compliance is as follows: at the level of regulatory philosophy, adhere to the free flow of enterprise data outbound under the premise of ensuring data security; at the level of regulatory logic, technically separate enterprise data from personal data and public data, and legally ensure reasonable ownership and classification governance of enterprise data. Following this train of thought, enterprise data should be categorized into detachable enterprise data and non-detachable enterprise data sets, and regulated based on data classification. Meanwhile, efforts should be made to actively promote the formulation and signing of WTO international treaties on enterprise data outbound compliance, and to establish bilateral mutual recognition mechanisms for cross-border compliance of enterprise data with countries along the Belt and Road Initiative, thus providing international guarantees for the classification and governance of enterprise data outbound compliance.

Keywords: cross-border flow of enterprise data; compliance governance; data classification and grading; international cooperation

责任编辑：乔雄兵